

MEDIDA CAUTELAR EM LICITAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 06-11-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-021098.989.24-7

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Representada: Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE - Cravinhos

Assunto: Representação contra o processamento do Pregão Eletrônico nº 14/2024, do tipo maior valor ofertado, que tem por objeto a *“prestação de serviços de administração, implementação, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de benefício alimentação aos servidores do SAAE”*.

Responsável: Lauro Catapani Filho (Diretor Superintendente)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP nº 288.403), Renato Chaves Pessini (OAB/SP nº 300.841).

=====

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM CHIP DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MAIOR VALOR OFERTADO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO INDEVIDO. ACEITAÇÃO DE TAXA NEGATIVA. BURLA À VEDAÇÃO CONTIDA NA LEI 14.442/2022. PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DO EDITAL E DOS ATOS SUBSEQUENTES.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA.** contra o processamento do Pregão Eletrônico nº 14/2024, do tipo maior valor ofertado, elaborado pelo **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE – CRAVINHOS**, que tem por objeto a *“prestação de serviços de administração, implementação, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de benefício alimentação aos servidores do SAAE”*.

1.2 Insurgiu-se a **REPRESENTANTE**, exclusivamente, contra a imposição de que a vencedora, no ato da assinatura do contrato, deposite o valor global ofertado em conta bancária da Autarquia Municipal.

Argumentou que tal exigência significa indevida *“outorga de concessão, a qual possui Leis próprias para sua regulamentação, quais sejam Lei 8.987/95 e Lei 9.074/95”*, mostrando-se, portanto, impertinente para o fornecimento de vale alimentação, submisso às regras da Lei nº 14.133/21.

Acrescentou que a contratação do serviço pretendido requer a existência de prévia dotação orçamentária.

Deste modo, sustentou que o ato convocatório deve ser reformulado, passando a indicar o prazo de pagamento à contratada do *“valor dos vales, considerando eventual taxa negativa que vier a ser ofertada pelas participantes”*.

1.3 Na hipótese, a representação foi protocolada fora do prazo para seu recebimento como exame prévio de edital, nos termos do artigo 220, § 3º, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Contudo, a relevância do aspecto impugnado e do critério de julgamento adotado (maior valor ofertado), em descompasso com o tipo de serviço pretendido (fornecimento de vale alimentação), mostraram-se suficientes para que a

peça fosse recebida nos termos do § 1º do artigo 214 da sobredita norma regimental.

Desta forma, a medida cautelar foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.4 Regularmente notificada, a **Representada** informou que já havia sido realizada a sessão de abertura das propostas, encontrando-se o certame em fase de adjudicação e homologação.

Além disso, afirmou que, *“no decorrer da disputa não houve quaisquer questionamentos, ou ainda a interposição de recursos, sendo que a própria empresa representante, participou da disputa e ofertou lances”*.

Defendeu que o torneio se destina à *“prestação de serviços a Administração Pública, e não a outorga de serviços a iniciativa privada”*.

Argumentou que a Lei nº 14.442/22, *“ao regulamentar o pagamento de auxílio alimentação no âmbito do PAT (aplicável ao caso), vedou a imposição de deságio ou desconto na remuneração da empresa fornecedora do objeto, extinguindo-se assim as chamadas: “taxas negativas”*.

Sustentou que, no caso, o certame teria aplicado o disposto no inciso III do artigo 3º, que impede *“o pagamento de: ‘outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculados diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do empregado, no âmbito de contratos firmados com empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxílio-alimentação’, ou seja, consigna a exceção de quando as verbas se destinarem à promoção de saúde e segurança alimentar do empregado”*.

Em linhas gerais, aduziu que o aporte financeiro se destina à assistência de saúde dos colaboradores, o que estaria em conformidade com a lei, pois se trata de verba vinculada diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do empregado. Assim, o valor aportado deve ser depositado na conta do SASSOF (Serviço de Assistência Social dos Funcionários

Municipais de Cravinhos), entidade que promove a assistência à saúde dos servidores, conforme regulamentado pela legislação local.

Para demonstrar sua tese, menciona a Lei Complementar municipal nº 12/1993, que instituiu o SASSOF, e a Lei Complementar municipal nº 16/1993, que descreve suas finalidades, bem como a Lei municipal nº 2467/2002, que regulamenta os valores ofertados ou benefícios vinculados para o SASSOF. Por fim, conclui que não haverá qualquer deságio entre o crédito e o posterior pagamento.

1.5 O Ministério Público de Contas pronunciou-se pela procedência da representação.

Destacou que a Portaria MTE nº 1.707/2024 veda a exigência de qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado, bem como a exigência de verbas não diretamente relacionadas à saúde e segurança alimentar do trabalhador.

Outrossim, avaliou que os benefícios oferecidos pelo SASSOF (Serviço de Assistência Social dos Funcionários Municipais de Cravinhos), como assistência à saúde e programas habitacionais, não se relacionam diretamente aos aspectos alimentares e nutricionais proporcionados pelo vale-alimentação.

Desta forma, obtemperou que a *“requisição de depósito de valor a ser destinado ao SASSOF, ainda que previsto em Lei Municipal, afronta ao artigo 3º, incisos I e III, da Lei n.º 14.442/2022 e à Portaria MTE n.º 1.707/2024, impondo a revisão da cláusula impugnada, o que por certo, alcança também o critério de julgamento adotado – ‘maior valor ofertado’.*

É o relatório.

2. VOTO

2.1 O Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE – Cravinhos pretende a *“prestação de serviços de administração, implementação, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de benefício alimentação aos servidores do SAAE”*.

2.2 No entanto, a instrução da matéria revela a impossibilidade de prosseguimento do certame nos moldes pretendidos pela Autarquia.

A adoção do julgamento pela maior oferta não se coaduna com o tipo de serviço pretendido (fornecimento de vale alimentação), constituindo, na verdade, uma forma de burlar a vedação, prevista na Lei nº 14.442/2022, ao oferecimento de taxa negativa pelas interessadas.

A tese da Autarquia de que o montante ofertado se destina diretamente à promoção de saúde, simplesmente pelo fato de que o depósito seria feito em conta bancária do Serviço de Assistência Social dos Funcionários Municipais de Cravinhos, não se sustenta.

Nesse sentido, bem elucida o percuciente parecer do MPC:

*“Neste ponto, importa registrar que a **Portaria MTE nº 1.707/2024**² do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece vedações e definições acerca do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, prevê que “a promoção da saúde e segurança alimentar do trabalhador deve referir especificamente a aspectos alimentares e nutricionais proporcionados pelo benefício” (art. 2º, § único) e que “entende-se como benefício vinculado **diretamente** à promoção da saúde e segurança alimentar do trabalhador aqueles relacionados à: I - promoção da alimentação adequada e saudável; ou II - realização de ações de educação alimentar e nutricional” (art. 3º):*

Art. 2º É vedado às pessoas jurídicas beneficiárias do PAT, no âmbito do contrato firmado com as fornecedoras de alimentação ou facilitadoras de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios, exigir ou receber:

I - qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado, ainda que em ofertas ou contratos paralelos cuja formalização dependa diretamente da adesão ao contrato a ser firmado com fornecedoras de alimentação ou facilitadora de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios; ou

II - verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculados diretamente à saúde ou segurança alimentar do trabalhador.

Parágrafo único. A promoção da saúde e segurança alimentar do trabalhador deve referir especificamente a aspectos alimentares e nutricionais proporcionados pelo benefício.

Art. 3º Para fins do disposto no art. 2º, inciso II, entende-se como benefício vinculado diretamente à promoção da saúde e segurança alimentar do trabalhador aqueles relacionados à:

I - promoção da alimentação adequada e saudável; ou

II - realização de ações de educação alimentar e nutricional. (grifos e destaques do MPC)

Consta, ainda, do art. 4º da referida Portaria que “são vedados quaisquer benefícios vinculados à saúde do trabalhador que não estejam diretamente relacionados à saúde e segurança alimentar e nutricional proporcionada pelo benefício, como serviços ou produtos relativos a atividades físicas, esportes, lazer, planos de assistência à saúde, estéticos, cursos de qualificação, condições de financiamento ou de crédito ou similares”.

O Serviço de Assistência Social dos Funcionários Municipais de Cravinhos – SASSOF, segundo Lei Municipal juntada no evento 36.5, possui “autonomia administrativa, financeira, patrimonial e orçamentária” (art. 1º) e tem por finalidade prestar aos servidores públicos municipais benefícios como “pensão, auxílio-maternidade, assistência à saúde, auxílio funeral, auxílio reclusão, reembolsos, empréstimos financeiros e programas habitacionais” (art. 2º):

DAS FINALIDADES
ARTIGO 2º:- O SASSOF tem por finalidade prestar aos servidores públicos municipais, na condição de filiados e aos seus dependentes, os seguintes benefícios:
I - BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS
a) pensão aos dependentes;
b) auxílio-maternidade;
c) assistência à saúde;
d) auxílio funeral;
e) auxílio reclusão.
II - BENEFÍCIOS FACULTATIVOS
a) reembolsáveis diversos,
b) empréstimos financeiros;
c) programas habitacionais.

No entanto, tais benefícios, conforme disciplinado na Portaria supracitada, não se relacionam diretamente à aspectos alimentares e nutricionais proporcionados pela oferta de vale-alimentação, impedindo, portanto, que se acate a tese da Administração de enquadramento da exigência como benefício destinado “à promoção de saúde e segurança alimentar do trabalhador”.

Nessa esteira, a requisição de depósito de valor a ser destinado ao SASSOF, ainda que previsto em Lei Municipal, afronta ao artigo 3º, incisos I e III, da Lei n.º 14.442/2022 e à Portaria MTE n.º 1.707/2024,

impondo a revisão da cláusula impugnada, o que por certo, alcança também o critério de julgamento adotado – “maior valor ofertado” (item 6 do edital³), questionado em decisão liminar.

Assim, tem-se a procedência da representação e do questionamento trazido em decisão liminar, devendo a Administração adequar o edital à legislação pertinente e à jurisprudência deste Tribunal”. (grifos originais)

Ademais, há de se destacar que tentativas similares de se esquivar da vedação imposta pela Lei nº 14.442/2022 já foram objeto de análise, e reprovação, por este Plenário, a exemplo do decidido recentemente, em sessão de 31-07-24, nos autos dos TCs-15172.989.24-6 e 15427.989.24-9¹:

“De fato, consoante manifestação do Parquet de Contas, o critério de julgamento adotado na espécie, de “maior desconto/repasse mensal”, no formato ora apresentado⁴, tem o condão de produzir, em concreto, os mesmos efeitos da taxa de administração negativa, em violação ao artigo 175, “caput”, do Decreto n.º 10.854/20215 e artigo 3º, inciso I, da Lei n.º 14.442/2022².

Com efeito, a diretriz avaliativa eleita in casu, que inclui o depósito, pela Contratada, junto ao Município, com posterior destinação ao Fundo Social de Solidariedade, do montante apurado a partir da aplicação do percentual de desconto sobre o valor total dos benefícios mensais creditados, acaba por contrariar a intenção revelada na exposição de motivos³ da Medida Provisória n.º 1.108, de 25/03/2022, posteriormente convertida na sobredita legislação federal:

19. Outra consequência adversa do modelo de arranjos de pagamento no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador é a possibilidade de concessão de taxas negativas ou deságio, pelas empresas emissoras dos vales refeição e alimentação, às pessoas jurídicas beneficiárias que recebem isenção tributária para implementar programas de alimentação a seus trabalhadores. Essa prática deturpa a política pública ao beneficiar duplamente as empresas beneficiárias. Ao conceder taxas negativas às pessoas jurídicas beneficiárias, as empresas facilitadoras de aquisição de refeições e gêneros alimentícios equilibram essa “perda” exigindo altas taxas dos estabelecimentos comerciais

¹ Relatora Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

² “Art. 3º O empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação de que trata o art. 2º desta Lei, não poderá exigir ou receber: I - qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado; [...]”.

³ Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=9096163&ts=1671475173927&disposition=inline>>. Acesso em: 29 jul. 2024.

credenciados, que de fato proveem a alimentação. Os trabalhadores, por sua vez, que deveriam ser os maiores beneficiários da política pública, se viram deslocados para a margem da política, enquanto as pessoas jurídicas beneficiárias ocupam o centro dela, ao ser beneficiado duplamente, com a isenção do imposto de renda e com as taxas de deságio concedidas pelas facilitadoras contratadas (destaquei).

É que o repasse ao referido Fundo do montante resultante da incidência do deságio na quantia a ser repassada aos funcionários da Prefeitura, suportado, a princípio, pela empresa contratada, é suscetível de ser embutido no valor final dos produtos adquiridos pelos beneficiários do vale e, até mesmo, pelos demais trabalhadores não pertencentes ao quadro da Origem, panorama que o plexo de normas correspondente visa combater.

Ademais, tal compreensão, restrita, a princípio, ao âmbito das entidades beneficiárias do Programa de Alimentação ao Trabalhador e aos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, estendeu-se aos demais órgãos promotores de certames com objetivos análogos, não inscritos no PAT, bem como a beneficiários estatutários, não celetistas, conforme voto de indeferimento de pedido de suspensão proferido pelo e. Conselheiro Robson Marinho, acolhido em Sessão Plenária de 06/04/2022, no âmbito do processo n.º TC-009245.989.22-3.

(...)

Nessa perspectiva, em certames como o que ora se apresenta, ainda que a Administração promotora da disputa não usufrua de incentivos fiscais decorrentes da promoção de programas de alimentação do trabalhador e de que seus funcionários não sejam regidos pela CLT, não lhe é lícito eleger qualquer diretriz de julgamento equivalente à admissão de apresentação de propostas com taxas de administração negativas, tendo em conta os normativos citados, vocacionados, precipuamente, a salvaguardar os interesses dos destinatários do benefício.

Logo, prosperam as impugnações tecidas com relação a essa temática, cabendo à Municipalidade alterar o critério de julgamento do torneio, qual seja, “de maior desconto/repasse”, deixando de adotar, inclusive, qualquer outro com efeitos equivalentes ao da taxa de administração negativa, e readequando, assim, todas as disposições correlatas”.

Destarte, inafastável a inviabilidade do critério de julgamento adotado, e via de consequência, da exigência do depósito do montante ofertado em conta do SASSOF.

Outrossim, nos moldes do precedente mencionado, deve a Autarquia alterar o critério de julgamento *“deixando de adotar, inclusive, qualquer outro com efeitos equivalentes ao da taxa de administração negativa, e readequando, assim, todas as disposições correlatas”*.

2.3 Posto isto, considero que o edital apresenta **vício insanável** relacionado ao critério de julgamento adotado, determinando, com fundamento na norma dos artigos 71, inciso III, e 171, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, que a Autarquia promova a **anulação** do Pregão Eletrônico nº 14/2024 e dos atos praticados em seu processamento.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO